

1002524-95.2021.8.26.0428
Classe: Ação Civil Pública
Assunto: Dano ao Erário
Magistrado: Carlos Eduardo Mendes
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo "tráfico de influência" nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios ilícitos".

No mesmo sentido pontua: "De forma geral, a improbidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulínia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002524-95.2021.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002524-95.2021.8.26.0428

Classe - Assunto

Ação Civil Pública - Dano ao Erário

Requerente:

1Ministério Público do Estado de São Paulo

Requerido:

José Pavan Júnior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de JOSÉ PAVAN JUNIOR, aduzindo, em síntese, que o requerido, exercendo à época o cargo de Prefeito da cidade de Paulínia, agiu em desconformidade com a lei, ensejando a presente demanda, a fim de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa em virtude de irregularidades reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do julgamento n. 004430/989/16-0.

Sustenta, que à época dos fatos o demandado chefiava o Executivo durante o os anos de 2015/2016 e, na oportunidade o TCE/SP apontou irregularidades no déficit na execução orçamentária correspondente a R\$ 67.495.691,57 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) (6,37%), da receita efetivamente arrecadada, aumentando consideravelmente o déficit financeiro para R\$ 163.734.304,84 (cento e sessenta e três milhões, setecentos e trinta e quatro reais, trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Nesse sentido, constatou também a fragilidade do planejamento revelado pelo elevado patamar de alterações orçamentárias, realizadas por meio de créditos adicionais,

suplementações remanejamentos, transferências e transposições no percentual de 36,63% da despesa inicialmente prevista.

Além disso, apurou que houve pagamentos de subsídios para agentes públicos, na qualidade de secretários, acima do valor estipulado por lei e aumento do subsídio do Prefeito e seu vice sem correspondência legal, gerando um gasto no montante de R\$ 817.501,05 (oitocentos e dezessete mil, quinhentos e um reais e cinco centavos), violando o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por conta disso, a Câmara Municipal de Paulínia editou o Decreto Legislativo n.º 267, de 25 de maio de 2021, o qual dispõe sobre a rejeição das contas do Poder Executivo Municipal de Paulínia referente ao exercício de 2016. Do mesmo modo, os próprios legisladores, de maneira maciça, reconhecerem as irregularidades apuradas pela E. Corte de Contas.

Diante disso, durante a execução de seu mandato, o requerido foi alertado por 06 (seis) vezes pela E. TCE/SP, todavia, não conteve o gasto não obrigatório e adiável.

Assim, o abuso nas alterações orçamentárias, perpetradas mediante abertura de créditos adicionais e de transferências, ensejou uma quantia de R\$ 448.359.383,61 (quatrocentos e quarenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), desfigurando por completo o orçamento do Município de Paulínia, de forma diversa da prevista na legislação orçamentária de Paulínia.

Isto posto, requer a distribuição e atuação da presente ação, instruída pelo representação n.º 43.0368.0000046/2021-1, bem como a expedição de ofício ao E. TCE/SP e à Câmara de Paulínia, para que repassem a remessa de cópia integral e digitalizada do eTC n.º 004430/898/16-0. Do mesmo modo, requer o conhecimento da prática de ato de improbidade administrativa subsumidos ao artigo 10, inciso IX e X e ao artigo 11, caput, e incisos I e II, ambos da Lei 8.429/92, condenando-o nas sanções previstas no artigo 12, inciso II, do mesmo diploma legal. Nesse sentido, pleiteia o ressarcimento integral do dano consistente no importe de R\$ 68.313.192,62, valor referente ao déficit financeiro gerado durante seu mandato, além dos aumentos salariais que se autoconcedeu.

Dessa forma, requer à perda da função pública que eventualmente estiver ocupando, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo certo de 08 (oito) anos, além do pagamento de multa civil no montante de 02 (duas) vezes o valor do dano. Requer à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 12, inciso II da mesma legislação. De forma subsidiária, requer a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso III da Lei 8.429/92. Ao final, protesta-se pelo recebimento da presente inicial e, posteriormente, sua integral procedência. Fixou a causa o valor de R\$ 68.313.192,62 (sessenta e oito milhões, trezentos e treze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos). Com a inicial, juntou procuração e documentos às fls. 34/2964.

Despacho às fls. 2965, intimando a parte ré, para que ofereça manifestação por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, como também a Municipalidade de Paulínia para que possa integrar a lida na qualidade de pessoa jurídica de direito público lesada.

Manifestação da Municipalidade às fls. 2968/2970, requerendo a formação do litisconsórcio ativo, admitindo-se a inclusão do referido Município.

Manifestação do Ministério Público às fls. 2989, com documentos às fls. 2990.

Deferido a expedição de mandado de notificação às fls. 2994.

Manifestação do Ministério Público às fls. 3004.

Regularmente citado e notificado o requerido ofertou resposta na forma de contestação às fls. 3011/3040. Inicialmente, aduziu que ao presente caso, aplica-se a nova legislação, em entendimento julgamento do Supremo Tribunal Federal ao tema 1.999, que trata das disposições da lei 14.230/21. Em sede preliminar, alegou a inépcia da inicial em razão da ausência de individualização das condutas imputadas ao contestante, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância ao artigo 17, § 6º, inciso I e 6º-B da Lei 8.429/92. Adiante, aludiu que não há indícios de prática de ato de improbidade administrativa, e que as

imputações foram fundadas apenas na rejeição das contas do ano de 2016, fato que, por si só, não configura ato de improbidade, conforme alguns precedentes do E. TJ/SP. Assim, apontou pela impossibilidade de responsabilização objetiva do agente, pela ausência de dolo específico. Diante disso, pugna pela aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa de forma mais benéfica ao peticionário para que seja reconhecida a atipicidade material das condutas subsumidas no artigo 10, inciso X da Lei n.º 8.429/92, pelo motivo da nova redação não autorize mais a tipificação do ato na prática de conduta culposa.

Posto isso, requer que seja reconhecida a atipicidade material das condutas subsumidas no artigo 10, inciso IX e artigo 11, inciso II, da mesma lei. Sendo assim, pugna pelo reconhecimento de excesso da acusação que tipifica a condenação em 04 (quatro) ilícitos diferentes, para uma única conduta praticada pelo requerido, logo, em inteligência ao artigo 17, § 10-F, do respectivo diploma legal, requer que o Ministério Público adeque as imputações formuladas, sob pena de incidir em bis in idem. No mérito, requer a total improcedência do feito. Juntou documentos às fls. 3041/3076.

Houve réplica às fls. 3080/3088.

Foi dado as partes o prazo de 15 (quinze) dias para especificarem as provas que pretendem produzir às fls. 3089.

Em manifestação às fls. 3094, o Ministério Público informou que não há provas a serem produzidas. Na mesma perspectiva, indicou o demandado às fls. 3095/3103. Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as questões relevantes ao julgamento da lide estão suficientemente dirimidas por meio da prova documental constante dos autos, não tendo o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Não há que se falar em inépcia da inicial, pois a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, valendo lembrar que dá narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, tanto que possibilitou ao requerido a contestação tempestivamente e rebatendo todos os argumentos lançados pela parte autora.

Ademais, é cediço que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do Código de Processo Civil).

Não há mais preliminares a serem analisadas, nem nulidades a serem declaradas de ofício. Por entender presente os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

No mérito, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Cuida-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de São Paulo, em que busca o reconhecimento como ato de improbidade a conduta do ex-Prefeito José Pavan Junior, nos termos do artigo 10, inciso IX e X e 11, ambos de Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992.

Como é cediço, o controle da Administração Pública quanto ao desempenho de suas funções tem por referência a consecução do interesse público, à vista do que em tese disciplinou o legislador, preordenando a atividade de entes, órgão e agente públicos para o exercício do poder político, concretizando a vontade política e determinando o curso de ação desejado ao Ente da Federação.

Assim, a Ação Civil pública é disciplinada pela Lei nº 7.347/1985 e tem por escopo, dentro outros aspectos, a proteção ao patrimônio público e social (art. 1, VIII, da Lei 7.347/85). São legitimados à sua proposição o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as Autarquias, as Empresas Públicas, Fundações ou Sociedades de Economia Mista e as Associações que

preenchem os requisitos cumulativos previstos no artigo 5º, inciso V, alíneas 'a' e 'b' da referida Lei. Patente, pois, o interesse de agir e a legitimidade do Ministério Público.

Aqueles que administram o patrimônio público, independentemente do ente federativo ou do Poder a que pertençam, devem respeitar rigorosamente a norma constitucional, aplicando os recursos públicos com estrita observância aos princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, isto é, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.

Por óbvio, a prudência deve ser redobrada quando se lida com a coisa pública, exatamente porque pertence a todos os cidadãos, que arcarão com as consequências, e não a um ente abstrato conhecido como "o Governo".

A inclusão do princípio da moralidade na Constituição Federal reflete a preocupação com a ética na Administração Pública.

Deste modo, a caracterização do ato de improbidade administrativa pressupõe flagrante descumprimento do dever constitucional de moralidade revelado de desvio ético, aperfeiçoado por conduta dolosa.

A respeito do assunto, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "(...) com a inserção do princípio da moralidade na Constituição, a exigência da moralidade estendeu-se a toda a Administração Pública, e a improbidade ganhou abrangência maior, porque passou a ser prevista e sancionada com rigor para todas as categorias de servidores públicos e a abranger infrações outras que não apenas o enriquecimento ilícito". (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo, editora Atlas, 25ª edição).

Embora nem toda irregularidade administrativa caracteriza improbidade, não se pode confundir o administrador inábil com o administrador ímprobo, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pontou:

"Para que o defeito de uma conduta seja considerado mera irregularidade administrativa, exige-se valoração nos planos quantitativo e qualitativo, com atenção especial para os bens jurídicos tutelado pela Constituição, pela Lei da Improbidade, pela Lei das Licitações, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e por outras normas aplicáveis à espécie. Trata-se de exame que dever ser minucioso, sob pena de transmutar-se a irregularidade administrativa banal ou trivial, noção que legitimamente suaviza a severidade da Lei de Improbidade Administrativa, em senha para a impunidade, business as usual" (REsp n. 892.818, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.11.2008).

Atento ao elemento subjetivo, tem-se que, quanto à caracterização do ato de improbidade administrativa, há três espécies de ato de improbidade: os que importam em enriquecimento ilícito (art. 9), os que causam prejuízo ao erário (art. 10) e os que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11).

Nesse sentido, entende Marino Pazzaglini Filho acerca do tema que "Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a prática de ato funcional ilegal, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. Para tipificá-lo como tal, é necessário que ele tenha origem em comportamento desonesto, denotativo de má-fé, de falta de probidade do agente público. Com efeito, as três categorias de improbidade administrativa têm a natureza intrínseca, que fica nítida com o exame do étimo remoto da palavra improbidade. O vocabulário latino improbitate, como já salientado, tem o significado de 'desonestidade' e a expressão improbus administrador quer dizer 'administrador desonesto ou de má-fé. E essa desonestidade, no trato da coisa pública, nos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, pressupõe a consciência da licitude da ação ou omissão praticada pelo administrador e sua prática ou abstenção, mesmo assim, por má-fé (dolo)" (Lei de Improbidade Administrativa Comentada).

Saliento que o ajuizamento da presente lide se deu em razão da suposta prática de atos de improbidade administrativa, consistente em diversas irregularidades, cujo afetou e muito o déficit da Municipalidade, haja vista que durante o mandato do requerido, o estrago nos cofres públicos se deu no montante R\$ 68.313.192,62

(sessenta e oito milhões, trezentos e treze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos). Logo, cumpre analisar a Lei nº 14.230/2021, cuja sanções alterou diversos dispositivos da Lei n. 8.429/1992.

Ressalta-se que, entre as alterações promovidas pela referida Lei, pode-se destacar a norma prevista pelo artigo 1º, §4º, da Lei nº 8.429/1992, que dispõe que “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”

Assim, a norma levou o Supremo Tribunal Federal a debruçar-se, recentemente, sobre a possibilidade, ou não, de aplicação retroativa das normas previstas pela Lei nº 14.231/2021, aos fatos praticados em data anterior ao seu início de vigência.

E ao proceder ao julgamento, o Plenário da Suprema Corte, por maioria, fixou as seguintes teses:

- “1). É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, a presença do elemento subjetivo, dolo;
- 2). A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
- 3). A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
- 4). O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporários a partir da publicação da lei”.

Assim, em linha geral, a improbidade administrativa costumeiramente é definida apenas como forma de moralidade qualificada a que se submete e que se exige dos agentes públicos e dos particulares colaboradores.

A rigor, é conceito mais denso. Trata-se da conduta divergente das normas morais, da lei e/ou dos costumes, indicando desonestidade dolosa em relação aos procedimentos esperados da administração pública, aqui em sentido amplo.

Com mais propriedade, Mario Pazzaglini Filho define que “Numa primeira aproximação, improbidade administrativa é o designativo técnico para o chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de Direito, democrático e Republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo “tráfico de influência” nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios ilícitos”.

No mesmo sentido pontua: “De forma geral, a improbidade administrativa não reclama tanta elaboração para que seja reconhecida. Estará caracterizada sempre que a conduta administrativa contrastar qualquer dos princípios fixados no artigo 37, caput da Constituição Federal, quais são legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, independente da geração de efetivo prejuízo ao erário”.

Apenas da Lei que trata do tema datar de 1992, o conceito último não é tão vago. Diz muito, sobretudo nos tempos atuais em que o País parece finalmente repudiar veementemente a vexatória situação de degradação moral em que os agentes públicos e particulares são surpreendidos.

Os princípios exemplificativos previstos nos artigos 9 a 11 da Lei n 8.949/92, tenho por improbidade administrativa como sendo quebra qualificada dos princípios norteadores do agente honesto.

Dessa maneira, a Constituição Federal em seu artigo 37 prevê:

“Art. 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao

seguinte.

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Necessário ressaltar, que após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, o artigo 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, passou a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelar a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado neste Lei os princípios constitucionais do direito administrativos sancionador”.

Neste contexto, imputa-se, originariamente, ao requerido a prática de atos de danos ao erário, previsto no artigo 10, inciso IX e X, da Lei de Improbidade Administrativa, tendo em vista que o próprio órgão acusador, readequou o seu pedido quanto a condenação ao artigo 11 inciso I e II, haja vista que os mencionados incisos foram revogados.

Em síntese, à luz do artigo e parágrafos supratranscritos, para a responsabilização dos requeridos por improbidade administrativa em qualquer uma de suas modalidades, é imprescindível a comprovação de dolo, isto é, consciência e vontade do agente. Outrossim, a referida lei, mais do que punir enriquecimento ilícitos e recuperar verbas desviadas, veio proteger os princípios basilares da Administração Pública, prevendo três espécies de atos de improbidade administrativa: o primeiro diz respeito daqueles que resultam de enriquecimento ilícito, previsto no artigo 9º lei; o segundo versa sobre os que causam prejuízo ao erário conforme dispõe o artigo 10º e; por último aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública, disposto no artigo 11.

Prescreve o supracitado dispositivo legal:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei”.

Nesse passo, tem-se que as condutas descritas no artigo 10 consistem em prática, pelo agente público, de um ato de forma contrária aos ditames da honestidade e da boa-fé, isto é, tratam-se de uma ilegalidade qualificada. Significa dizer que mera ilegalidade não se confunde com o dolo do agente em praticar a conduta ímproba.

Cumprе consignar que, para configuração das condutas elencada no artigo, ora referido, com as devidas alterações promovidas pela Lei 14.231/21, passou a se exigir a demonstração de dolo pelo agente. O parágrafo 1º do artigo 1º, do mesmo diploma legal, na nova redação, dita que:

“§1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais”.

Os parágrafos 1º e 3º do mesmo artigo, inclusive, caracterizam na letra da lei o

conceito de dolo que se reputa necessário:

“§2º. Considera-se dolo a vontade consciente e livre de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Assim, portanto, consoante se deduz das disposições encimadas, para a caracterização dos atos de improbidade exige-se a configuração do dolo específico. A esse respeito, ensina a melhor doutrina:

“O dolo específico, especialmente para os fins de caracterização de ato de improbidade, é o ato eivado de má-fé. O erro grosseiro a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterizarão atos de improbidade (...) Com efeito, não basta mais, segundo correta interpretação da LIA, alegar que ato é doloso, ou demonstrar que é ilegal. Sob o regime do novo diploma, é necessário se demonstrar a má-fé, uma intenção de lesar, alguma forma de conluio entre agentes”.

No ponto, vale trazer à baila os ensinamentos do professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, relacionados a essa matéria:

“Há três de corrupção que, salvo melhor juízo corresponderia aos três grandes grupos de atos de improbidade administrativa definidos na Lei nº 8.429/92, a saber: a corrupção suborno, que é a corrupção por meio de retribuição e que estaria configurada nas condutas do artigo 9º, (atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento); a corrupção favorecimento, que é a condenação que resulta do privilegiamento do privado em detrimento do público e que corresponde às condutas descritas no artigo 10 (atos de improbidade que causam prejuízo ao erário); e a corrupção-solapamento, que atinge o próprio fundamento íntimo da legitimidade e que estaria consubstanciado nas fórmulas de conduta do artigo 11 (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública”.

A esse propósito, o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, destaca:

“O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a qualquer tendência de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual irrompem, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antidoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do anterior esquema de poder assentado na relação soberano súbito”.

Como é amplamente vinculado, a Lei de Improbidade Administrativa não pune a mera ilegalidade, mas, sim, a conduta imoral dos agentes públicos. exige-se, para a consumação de tal ato, um desvio de conduta dos agentes, apartado dos padrões éticos e morais, com o fito de obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízo ao patrimônio público, ainda que não se logre êxito nesses desideratos. Em uma palavra “a lei tutela a retidão e a honestidade no trato da coisa pública. Nesse diapasão, leciona Marino Pazzaglini Filho:

“A improbidade administrativa, sinônimo jurídico de corrupção e malversação administrativa, exprime o exercício da função pública com desconsideração aos princípios constitucionais expressos e implícitos que regem a Administração

Pública.

Improbidade administrativa é mais que mera atuação desconforme com a singela e fria letra da lei. É a conduta denotativa de subversão das finalidades administrativas, seja pelo uso nocivo (ilegal e imoral) do Poder Público, seja pela omissão indevida de atuação funcional. Decorre tanto da desonestidade e da deslealdade, quanto da inidoneidade ou da incompetência do agente público no desempenho de suas atividades funcionais.

Diante do exposto, é possível conceituar a improbidade administrativa do agente público: toda conduta ilegal (corrupta, nociva ou inepta) do agente público, dolosa ou culposa, no exercício (ainda que transitório ou sem remuneração) de função, cargo, mandato ou emprego público, com ou sem participação (auxílio, favorecimento ou indução) de terceiro que ofende os princípios constitucionais (expressos e implícitos) que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a improbidade administrativa constitui violação ao princípio constitucional da probidade administrativa, isto é, ao dever do agente público de atuar sempre com probidade (honestidade, decência, honradez) na gestão dos negócios públicos". (Lei de Improbidade Administrativa Comentada, São Paulo: Atlas, 2002).

Significa dizer que a improbidade não é sinônimo de mera ilegalidade administrativa, mas de ilegalidade qualificada pela imoralidade, pela má-fé, pela falta de probidade no desempenho da função pública, o que se verifica quando a conduta reputa ilegal, animada pela má-intenção do administrador público, fere princípios da Administração Pública. É a má-fé que aparta a inabilidade, ou mesmo a incompetência do agente público, da improbidade administrativa.

Isto posto, o cargo exercido pelo requerido, requer a probidade e aptidão para o bom desempenho da função pública, uma vez que o Prefeito, é figura de comando de uma cidade e responsável por todos os atos executados sob sua gestão.

O pedido condenatório, demanda a comprovação do prejuízo, experimentado pelo Poder Público, ainda que imaterial. Como se sabe, o pressuposto da indenização é o desfalque patrimonial causado por ação ou omissão dolosa ou culposa.

Nessa perspectiva, a configuração de ato ímprobo reclama, necessariamente, a demonstração do elemento subjetivo do envolvido, traduzido em dolo ou culpa, conforme capitulação legal, o que neste caso em apreço, ficou devidamente demonstrado.

Diante da farta produção de provas acostadas nos autos às fls. 34/2964, é possível verificar as condutas descritas na inicial, uma vez que o ex-Prefeito, ora demandado, foi avisado em 06 (seis) oportunidades pelo Tribunal de Contas, sobre as suas responsabilidades no manuseio do dinheiro público. De maneira diversa, o réu extrapolou todas as barreiras possíveis, gerando um déficit bastante superior ao da gestão anterior, ensejando um valor extremamente considerável, na casa dos milhões. Outro ponto crucial para a parcial procedência do feito, refere-se ao aumento dos subsídios dos agentes públicos, na qualidade de secretários, inclusive do Vice-Prefeito e do próprio réu (ex-Prefeito), o qual também gerou um gasto extremamente considerável no importe de R\$ 817.501,05 (oitocentos e dezessete mil, quinhentos e um reais e cinco centavos). Cabe ressaltar, que este ato se deu fora dos ditames da legislação.

Posto isto, a responsabilização do gestor público decorra de violação a princípios administrativos como o da moralidade, por exemplo, não poderá ser condenado a ressarcir o erário se não houver prova concreta da lesão ao patrimônio público.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de concluir que: ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE - CONFIGURAÇÃO. Esta Corte, em precedente da Primeira Seção, considerou ser indispensável a prova de existência da dano ao patrimônio público para que se tenha configurado o fato de improbidade, inadmitindo o dano presumido. Ressalvado entendimento da relatora. 2. Após divergências, também firmou a Corte que é imprescindível, na avaliação do ato de improbidade, a prova do elemento subjetivo. (RECURSO ESPECIAL Nº. 621.415 - MG R. MINISTRA ELIANA CALMON). Também há de se destacar, porque relacionado com os fatos da demanda em apreço, o princípio da moralidade, o qual impõe a obrigatoriedade de o agente administrativo agir com honradez e dignidade na condução e no "trato dos assuntos que lhe são

afetos", pois "por consideração de Direito deverá também decidir entre o honesto e o desonesto". Por consideração do Direito deverá também decidir entre o honesto e o desonesto. Por consideração do Direito e da Moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição porque nem tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos".

Nesse diapasão, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo que "o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo, mas por legalidade e legitimidade se entende não só a conformação do ato com a Lei, como também com a moral administrativa e com interesse coletivo".

Com efeito, o autor apresentou provas substanciais e suficiente para comprovar, de modo assertivo, todo o explanado na exordial. A conduta do réu é, por obvio, ilícita, caracterizada e descrita na Lei que versa sobre a improbidade.

Compete exclusivamente ao Ministério Público, comprovar tal circunstância, ante o seu ônus processual (art. 373, do CPC), diante disto, cumpriu de forma perfeita o seu encargo, hábil a ensejar a condenação pretendida.

Como cediço, consoante a jurisprudência, para a condenação por ato de improbidade administrativo, é imprescindível a conduta do agente, o que neste caso, restou devidamente caracterizada.

Em virtude disso, o Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovado pela Câmara Municipal da cidade, comprovam que houve irregularidades no mandato do réu, munido, posteriormente de outras provas que sustentam de forma cabal a pretensão autoral, recaindo sobre o ex-Prefeito a conduta de improbidade administrativa, disposta no inciso IX e X do artigo 10, da Lei 8.429/92:

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X - agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Consequentemente, os documentos às fls. 475/1122, demonstram a conduta de má-fé do requerido, que à época ocupava o cargo de Chefe do Poder Executivo da cidade de Paulínia. O legado deixado por ele, é totalmente incondizente com a postura e conduta que se espera de um agente que ocupa o cargo em questão.

Dentre as folhas acima mencionadas, é possível verificar os relatórios do Tribunal de Contas, em que expõe a situação dos bens públicos e o estado em que se encontra, sendo este, totalmente incondizente com o interesse público.

Denota-se, a quantidade de despesas não autorizadas, inclusive do aumento dos subsídios do próprio réu e de seus secretários, que como supracitado, por si só, gerou danos ao erário.

Não há tese de defesa capaz de sustentar que a conduta do réu foi eivada de boa-fé, sabendo-se que o mesmo é reiteradamente denunciado pelo Órgão Ministerial, diante das inúmeras irregularidades encontradas durante a sua gestão.

Assim, não há como alegar que não houve dolo na conduta do demandado, uma vez que o Chefe do Poder Executivo, sabe, ou ao menos deveria saber de suas responsabilidades e atribuições, a passo que o cargo exercido pelo requerido requer extrema aptidão e responsabilidade, levando em conta que as ações ou omissões do agente, acarretará prejuízos irreparáveis ao coletivo, semelhante ao do caso em comento.

Por óbvio e como mencionado a conduta gerou um largo prejuízo à saúde financeira da Municipalidade, resultando em um déficit no importe de R\$ 68.313.192,62 (sessenta e oito milhões, trezentos e treze mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

No tocante ao déficit, é notório que tal fato contraria o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual prevê que "é vedado ao titular do Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito".

O mencionado artigo, foi contrariado no momento em que o demandado realizou o aumento de subsídios dos agentes públicos, quais sejam os secretários municipais,

acima do valor fixado em lei. Não o bastante, os subsídios do Vice-Prefeito e Prefeito, ora réu, também foram alterados sem que existisse fundamentação para tal ato. Além disso, as contratações junto as empresas responsáveis por efetuarem o serviço de manutenção e reestruturação de prédios públicos também afrontam o referido dispositivo legal, pelo elevado valor envolvido nas negociações.

De outro lado, o requerido foi alertado por diversas vezes durante o ano de 2016, que se não tomasse alguma medida, extrapolaria os gastos permitidos em lei e, posteriormente, não atenderia a responsabilidade fiscal inerente a todo e qualquer órgão público.

Por oportuno, cabe pontuar que diante da conhecida dificuldade dos Chefes do Poder Executivo em controlar e adequar as contas públicas nos orçamentos municipais, este valor apontado acima, é extremamente elevado e em momento algum pode ser analisado como algo comum e aceitável.

Desta forma, a má-fé na conduta do agente está devidamente caracterizada. Consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do agente.

A improbidade administrativa, mais do que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade, o que de forma cristalina restou demonstrado cabalmente nos autos, diante do farto conjunto probatório produzido.

Dessarte, o dano, no terreno do Direito da Improbidade Administrativa, não é avaliava exclusivamente sob a ótica patrimonial, mas, com muito maior apelo, sob a égide social e moral.

Assim, como a negligência nos cuidados à res publicae seja patente, de fácil modo, se vislumbra a ocorrência de má-fé na conduta dos réus, pelo simples fato de terem agido com o escopo de prejudicar a Municipalidade.

De modo tempestivo, trago à baila, a fim de fortalecer a presente decisão os ensinamentos de Marcello Caetano, "o funcionário deve servir à Administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções sempre no intuito de realizar os interesses públicos, sem aproveitar os poderes ou facilitar delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queria oferecer". (Manual de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Forense, 1970).

Desta maneira, como é amplamente sabido, em que pese a primazia do interesse público e a necessidade de se assegurar o patrimônio e o respeito aos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, Direta ou Indireta, com o advento da nova Legislação, não pode eventual condenação por ato de improbidade embasar-se em juízo de probabilidade, devendo o dolo do agente exsurgir de forma clara e extrema de dúvidas dos elementos de prova coligidos aos autos, o que de forma reiterada se verifica no caso em comento.

Reforço, pois, que houve conduta ímproba passível de condenação.

Portanto, exigindo-se o dolo para punição, o qual restou demonstrado, é de rigor procedência do feito.

De tal maneira, formo meu convencimento, nos moldes do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de JOSÉ PAVAN JUNIOR, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de reconhecer ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10, inciso IX, da Lei n.º 8.429/92, e CONDENAR o requerido nas penas previstas no artigo 10, do citado diploma legal, ao ressarcimento integral do dano, a perda da função pública que eventualmente estiver ocupando, suspensão dos direitos políticos pelo prazo certo de 08 (oito) anos, bem como a proibição de contratar junto ao Poder Público, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 12, inciso II, da Lei n.º 8.429/92.

Condene o requerido no pagamento de custas, despesas processuais e honorários

advocatícios, nos termos dos artigos 18 da Lei nº 7.347/1985, Lei da Ação Civil Pública.

Transitado em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos do demandado e proceda-se à inclusão do aqui disposto no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paulinia, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA